

114年公務人員特種考試司法官考試第二試
114年專門職業及技術人員高等考試律師考試第二試
法律專業科目評分要點與閱卷委員的話

科目：公司法、保險法與證券交易法

第一題

【總題說明】

本題主要測驗股份有限公司經理人競業禁止規範如何適用，以及監察人應負之忠實義務與法律效果，並探討裁判解任監察人之要件與卸任後再選任對解任訴訟產生之影響。具體而言，包括以下爭點：

- 一、經理人不得自營或為他人經營同類業務，是否包括擔任他公司監察人？經理人擔任他公司監察人後，再擔任從事相同業務公司之董事，是否可行？
- 二、監察人是否對公司負忠實義務？倘因執行職務得知公司重大訊息進而買賣公司股票獲取利益時是否違反忠實義務？若肯定，公司能否對該監察人行使歸入權？
- 三、本案事實是否符合公司法裁判解任監察人之要件？裁判解任訴訟程序中監察人任期屆滿卸任後再當選，是否對法院解任監察人有影響？

【評分要點】

第(一)子題

1. 公司經理人兼任他公司監察人、董事是否構成競業行為？

- (1) 依公司法第 32 條規定：「經理人不得兼任其他營利事業之經理人，並不得自營或為他人經營同類之業務。但經依第 29 條第 1 項規定之方式同意者，不在此限。」此乃經理人兼職與競業禁止規範。依題示，甲無兼任其他營利事業之經理人，但擔任他公司監察人、董事可能構成競業行為。
- (2) 甲為 C 公司經理人，當選為 B 公司監察人，是否違反前開競業禁止規定？所謂經理人「不得自營或為他人經營同類之業務」，是否包括擔任他公司之監察人？此涉及監察人職務是否屬於「經營業務」。監察人職務主要為監督公司業務之執行(公司法第 218 條)及財務會計之審核(公司法第 219 條)，且於特定情形下，尚具有法律行為代表權(公司法第 223 條)及訴訟代表權(公司法第 213 條)，似不屬於「經營業務」。

- (3) 其後，甲又當選 D 公司董事，由於 C、D 兩公司為同類業務，因此，甲為 C 公司經理人，在未得該公司同意時再擔任同類業務之他公司董事，似違反公司法第 32 條之競業禁止規定。

2. 監察人是否負有競業禁止之義務？

- (1) 雖有認為監察人監督公司負責人之職務，對公司業務機密知之甚詳，且可行使監察督導之權，若得為競業行為，易生擅權偏私或洩漏公司機密之事，危害公司甚鉅。惟在法無明文下，依體系解釋，公司法第 227 條並未準用同法第 209 條規定，另外，監察人並非職司公司業務之執行，似無禁止競業之必要。因此，監察人似可擔任為相同業務他公司之董事。
- (2) 本題未明示 B 公司是否同屬於生物科技生產及研發為業（雖其持股百分之 45 之 A 公司係從事生物科技生產及研發），但如前分析，甲當選 B 公司監察人後，似仍可再擔任 D 公司董事。

第(二)子題

1. 本題無證券交易法內線交易規定之適用

因 B 公司為非公開發行股票公司，故該公司股票買賣無涉及證券交易法相關規定之適用，合先說明。

2. 監察人應對公司負忠實義務

倘監察人因執行職務得知公司重大訊息進而買賣公司股票獲取個人利益時違反忠實義務，公司得對其行使歸入權。

- (1) 監察人在執行職務範圍內亦為公司負責人(公司法第 8 條第 2 項)，應對公司負注意義務與忠實義務(公司法第 23 條第 1 項)。
- (2) 在忠實義務要求下，負責人不得追求自己或第三人利益而犧牲公司利益，行為態樣包括自我交易、利用公司機會等。監察人因執行職務獲悉公司重大訊息，此似屬公司資源，甲私自利用 B 公司重大訊息向 B 公司股東買進股票，似違反公司法第 23 條第 1 項規定。若因此獲有利益，公司得依公司法第 23 條第 3 項，經股東會決議，請求甲將所得利益歸入公司。但應自所得產生後 1 年內為之。

第(三)子題

1. 是否符合裁判解任要件

依公司法第 227 條準用第 200 條，監察人執行業務，有重大損害公司之

行為或違反法令或章程之重大事項，股東會未為決議將其解任時，得由持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東，於股東會後三十日內，訴請法院裁判之。監察人甲因執行業務機會獲取 B 公司重大訊息，進而利用買賣公司股票而獲利，已違反忠實義務，似構成「重大損害公司之行為」或「違反法令之重大事項」。倘股東丁符合其他要件，如持股比例百分之 3、解任甲之議案經 B 公司股東會決議未予解任，即符合裁判解任要件。

2. 被訴監察人甲卸任再當選之效果

如前所述，B 公司為非公開發行股票公司，關於對甲之解任訴訟，應無證券投資人及期貨交易人保護法（下稱投保法）第 10 條之 1 之適用。訴訟進行中，甲因任期屆滿卸任再選任時，由於公司法並無如投保法有「解任事由不以起訴時任期內發生者為限」、「失格制度」等明文規定。故丁之裁判解任訴訟是否仍具有訴訟利益，似有疑問。即使有訴訟利益，能否以前任期發生事由作為裁判解任之事由，亦有疑義。雖然依投保法第 10 條之 1 司法實務傾向肯定見解，但在公司法之裁判解任訴訟仍未有定論。

【閱卷委員的話】

本題主要測驗應考人對於經理人、監察人等職務負責人之競業義務、忠實義務以及裁判解任要件與程序等規定之適用問題。由於三子題問題明確，且涉及具體條文，故應考人僅要知曉相對應條文，皆能有基本的作答。惟，或許因為涉及公司家數、甲重複擔任職務過多，造成少數應考人誤解題意，致使其作答未能緊扣問題核心。在第(一)子題「甲兼任 B 公司監察人是否合法？」、「又當選 D 公司董事是否構成競業行為？」，係分別以甲擔任 C 公司經理人與 B 公司監察人角度出發，而非指擔任董事後之競業禁止行為。但不少應考人於本題討論到董事競業禁止規定（公司法第 209 條）之適用問題。在第(二)子題中，不少應考人忽略 B 公司為非公開發行股票公司，並無證券交易法內線交易規定之適用。也有不少應考人提到可類推適用公司法第 209 條董事歸入權。惟監察人之忠實義務與違反效果，已有公司法第 23 條第 1 項與第 3 項得以適用，似無再類推適用董事競業禁止規定之必要。

在第(三)子題探討解任訴訟之構成要件時，或許題目未言明，少數應考人即假定該條件不存在，如起訴股東丁持股比例不足、解任議案未經股東會決議等，即逕否定丁不符合提起解任訴訟的要件，但如此未以其他可能情況探討要件是

否該當，致使作答不完整。就甲卸任後再度當選法院得否解任甲的問題，因 B 公司為非公開發行股票公司，多數應考人認為可類推適用證券投資人及期貨交易人保護法（下稱投保法）第 10 條之 1 關於裁判解任訴訟的規定，或者，依該規定所揭示之法理，肯認法院仍可以裁判解任甲。惟本問題亦涉及董事卸任再就任，裁判解任訴訟是否能續行之問題。投保法引入董事失格制度後，董事即使卸任，不論是否再度當選，司法實務認為解任訴訟仍有訴訟利益。惟公司法之裁判解任訴訟並無失格效果，董、監事卸任後再度當選，該裁判解任訴訟是否有訴訟利益，似仍需討論，但僅有少數應考人有意識此一爭點。

整體而言，多數應考人對本題都能有基本的應答，因本題問題明確，故作答都有不錯的表現。然部分因題目未明示特定條件，而即予肯定或否定解答，致答題過程未能詳細討論而不夠完整。另外，部分應考人誤解題意，致作答未能觸及全部核心問題，較為可惜。

第二題

【總題說明】

本題旨在測驗考生對於財產保險之保險利益、保險標的之價值認定、複保險與保險競合、保險代位與再保險之熟悉度與瞭解。

【評分要點】

第(一)子題

1. 保險利益

首先，甲與乙對該屋有共同出資並一同居住，不論從房屋之財產價值或使用權利而言，兩人對該屋均有保險利益，此狀態至事故發生時並未變更。對於財產保險，我國保險法第 17 條規定：「要保人或被保險人，對於保險標的物無保險利益者，保險契約失其效力。」通說認為要保人應具備保險利益，且在事故發生時具備即可。依本題事實，足認為兩人均符合要件，所訂立之保險契約均為有效。

2. 保險標的價值之認定與時點

保險法第 73 條第 3 項規定：「保險標的未經約定價值者，發生損失時，按保險事故發生時實際價值為標準，計算賠償，其賠償金額，不得超過保險金

額。」故在保險事故發生時，賠償金額，不得超過保險金額，以符合損害填補原則。本題保險事故發生時，建物之價值為 1 千萬元，故賠償金額亦應以此為度。

3. 複保險與保險競合

除了單一保險可能有超額填補之問題，這在多數保險亦可能發生，此即為複保險或保險競合之問題。參照保險法第 35 條：「複保險，謂要保人對於同一保險利益，同一保險事故，與數保險人分別訂立數個保險之契約行為。」本題兩張保險契約係以該屋之火災保險為保險事故，保險利益與保險事故均同一，且期間重疊，又兩張契約之保額相加達 1 千 2 百萬元，已經超過 1 千萬元之保險價值。但本題兩張保險契約分屬不同要保人所訂立，如認為複保險之成立應以要保人同一為必要，則本題不構成複保險，而應由後述之保險競合處理。如認為可就要保人是否同一做寬鬆解釋，而仍得繼續討論複保險之適用。本題當事人屬於善意，故屬於善意複保險。依保險法第 38 條規定：「善意之複保險，其保險金額之總額超過保險標的之價值者，除另有約定外，各保險人對於保險標的之全部價值，僅就其所保金額負比例分擔之責。但賠償總額，不得超過保險標的之價值。」故善意複保險原則上以比例分擔損失，但當事人仍可作其他約定。本題 A 產物保險公司之契約條款，屬於不負責任條款；而 B 產物保險公司之契約條款，則屬於溢額責任條款。當此兩個種類相異之條款競合時，為了避免逃避責任，保險實務上多認為由不負責任條款之保險人優先理賠，不足的部分再由溢額條款之保險人理賠。此類條款或伴隨較低之費率或條件，是否當然顯失公平，仍得進行討論。另如認為該契約條款，皆因與保險法第 38 條比例分擔有別，而有違保險法第 54 條第 1 項但書或第 54 條之 1 構成顯失公平，致該契約條款無效者，則回歸適用保險法第 38 條，以保額比例分擔。

4. 小結

綜上，如採不負責任條款優先理賠之見解時，A 應優先理賠，故應理賠 6 百萬元；B 就剩餘之 4 百萬元損失負理賠之責任。另如認為適用比例分攤，則 A、B 分別應負 500 萬元。

第(二)子題

1. 保險代位及例外

乙所聘之員工丙故意縱火致該屋完全毀損，故可能有保險法第 53 條保險代位之適用。此處應檢驗保險代位的適用要件，該條規定：「被保險人因保險人應負保險責任之損失發生，而對於第三人有損失賠償請求權者，保險人得於給付賠償金額後，代位行使被保險人對於第三人之請求權；但其所請求之數額，以不逾賠償金額為限。前項第三人為被保險人之家屬或受僱人時，保險人無代位請求權。但損失係由其故意所致者，不在此限。」丙因故意造成事故發生，故仍有保險代位適用。因此，A 與 B 理賠後，可向丙代位求償。

2. 保險代位與再保險之適用關係

另外，A 產物保險公司就火災保險業務，有向 C 再保險人投保分保比例 50% 之再保險。如認為保險代位本質屬於法定債權移轉，則保險代位是否適用於再保險，是否亦有法定債權移轉之效果，而使保險代位數額必須扣除再保險給付，則有問題。依照國際保險實務慣例與我國多數見解，A 代位求償時不需扣除再保險給付，仍可全部代位求償。在理論基礎方面，德國之理論為再保險為商人保險而非消費者保險，故無保險代位的適用，而由當事人自行商議決定即可。日本雖然認為保險代位屬於法定債之移轉，但仍肯定再保險有保險代位適用，只是通常再由再保險人委由原保險人一併求償。如採英美法之體系者，則其保險代位並非法定債之移轉，故不需要否認再保險有保險代位的適用。再保險人既然可以享受代位的利益，自然是適用保險代位的結果。據此，再保險人在必要時，仍得主張保險代位。但不論採取何種理論，均應肯定代位求償時不需扣除再保險給付。

3. 小結

A 與 B 理賠後，均可向丙代位求償，且 A 之代位求償金額不需要扣除 C 之再保險攤回。

【閱卷委員的話】

本次閱卷考生大部分都能掌握第(一)子題所應解決之爭點，尤其涉及是否構成複保險以及學說或實務上關於保險競合等概念，普遍只要能提出對於契約條款約定與現行法複保險間之分析，就其與複保險之構成要件或保險法第 38 條有所討論，進而檢視契約條款是否違反保險法第 54 條第 1 項但書以及保險法第 54 條之 1 等有无顯失公平等，都會有不錯的分數。另外亦有不少考生就「保險競合」概念論述本題，並討論不負責任條款與溢額條款如有衝突時，應以何者為

優先賠付，也會評予不錯分數。

但大部分對於第(二)子題保險代位與再保險之考點則答題狀況不佳。大部分考生都能先探討受僱人與保險法第 53 條第 2 項但書之適用，但或許因時間不夠或答題不夠謹慎而忽略本題主要仍在探討再保險契約如給付後，保險人對於第三人所得主張之權利，是否亦隨同移轉於再保險人？雖然本爭點近年來較少爭議，但過往不論實務判決或學說亦有不少討論，少數考生仍能區辨本題考點，成為高分關鍵。

第三題

【總題說明】

本題主要涉及證券交易法（下稱證交法）第 20 條第 2 項、第 20 條之 1 關於財報不實之損害賠償責任，包括以下爭點：

- 一、依證交法第 20 條之 1 請求損害賠償之請求權人，包括：善意取得人、持有人。
- 二、依證交法第 20 條之 1 請求損害賠償之賠償義務人，包括：發行人、會計師，以及其責任要件。
- 三、依證交法第 20 條之 1 請求損害賠償之因果關係（包括：交易因果關係與損失因果關係）與舉證責任。
- 四、2006 年 1 月 11 日證交法修正時，賦予證券持有人賠償請求權，該修正之適用範圍。

【評分要點】

一、乙可向 A、甲請求損害賠償

（一）乙係證交法第 20 條之 1 之善意取得人

乙於不實財報公布後購買 A 公司股票，係取得人；其購買時，不知財報有虛偽或隱匿情事，係「善意」取得人。

（二）A、甲係證交法第 20 條之 1 之賠償義務人

1. A 公司係發行人，依第 20 條之 1 第 1 項為賠償義務人。且因無法證明已盡相當注意，且有正當理由可合理確信其內容無虛偽或隱匿之情事者而免責，負無過失責任。
2. 甲係會計師依第 20 條之 1 第 3 項，若有不正當行為或違反或廢弛其業務

上應盡之義務，應負損害賠償責任。原告須證明會計師有過失，始應負責，屬一般的過失責任。本題中，會計師甲因疏失而未能發現 A 公司隱匿了投資重大虧損而未予揭露，仍予以無保留意見之簽證，顯有過失。

(三) 因果關係、舉證責任與抗辯事由

就交易因果關係是指原告因相信不實財報而購入股票，本題投資人乙從未看過 A 公司財報，但仍然大量購入 A 公司之股票，是否具交易因果關係？司法判決有以民事訴訟法第 277 條為基礎，引進美國法之詐欺市場理論，推定原告之交易因果關係，有判決指出：

1. 「公開說明書及財務報告之內容，往往使用諸多專業術語，如未具有相關之會計、財經或法律等專業知識，尚難瞭解其所述內容，且一般非專業投資人大都並無參酌財務報告以決定其購買意願，亦屬實情」。
2. 「然查，在公開市場為股票交易者並非僅限於非專業投資人而已，專業投資者（如投資信託公司及外國資金等）參與股票買賣，更為股票交易之主要對象，而各該專業投資者均聘僱有相關專業人員從事各項財經資訊等影響股票行情因素之分析、研判，並提出投資意見以供是否進場交易之參考，此為眾所周知之事實」。
3. 「此類專業投資者，對各該上市、上櫃公司之財務報告，既本其專業知識為研判分析，藉以決定是否交易買賣，並使一般非專業之投資大眾因此而跟進或為參與交易之決定，則在整體交易市場之運作下，任何以不實資訊公開於股票交易市場之行為，應均可視為對參與股票交易之不特定對象為詐欺，並進而推定任何參與股票交易之善意取得人或出賣人，均有信賴該資訊之真實性，而不須舉證證明其有如何信賴財務報告之事證，亦即該交易因果關係係被推定，此從證交法第 20 條規定之意旨觀之，亦可得佐證，並為美國就有關股票交易訴訟時所發展出之『詐欺市場理論』所採用」。
4. 「況依民事訴訟法第 277 條但書規定，如舉證分配之情形顯失公平者，並非必然由主張有利之事實者為舉證，而本件係屬股票交易下所生之損害，就其交易型態係藉由公開市場及信賴公開資訊交易而言，如將舉證責任責由原告為之，勢將產生舉證其信賴財務報告而交易上之重大困難，且亦違反公開資訊者應確保其資訊真實性之原則，故本院認上開因果關係推定之見解，應可適用於本件爭議，故原告僅須舉證證明財務報告內容不

實，即可受推定已就交易因果關係部分盡其舉證責任」(高雄高分院 94 年度金上字第 1 號民事判決)。

由於交易因果關係為推定，被告可反證原告買賣證券與不實財報之間不具因果關係之抗辯。

就損失因果關係，即原告因不實財報購入股票致生財產損失，仍應由原告負舉證責任。法院有以不實資訊遭拆穿或更正後，股價明顯下跌，而認定具損失因果關係。

二、丙可向 A、甲請求損害賠償

(一) 丙係證交法第 20 條之 1 之善意持有人

1. 2006 年 1 月 11 日證交法修正時，賦予證券持有人賠償請求權，其立法理由指出：「為使投資人之保護更形周延，除對於善意信賴財務報告及財務業務文件而積極為買賣行為之投資人明定其損害賠償之請求權外，對於該有價證券之持有人，亦明定其損害賠償請求權」。考其意旨，可能是因投資人雖在不實財報公布之前買進，但買入後公司公布不實財報，投資人誤信公司財務良好，故未賣出，俟不實財報揭穿後，因股價下挫受有損害，因而賦予求償權。本題丙在不實財報公告前買入，原本預計在股價高檔賣出持股，但見 A 公司蒸蒸日上之外觀而打消原意，繼續持有股份，屬善意持有人。
2. 然而，丙在民國 90 年即買進 A 公司股票，亦即於 2006 年 1 月修法前買進，是否得依善意持有人而請求損害賠償？金管會函釋指出：「按證券交易法第 20 條之 1 規定，財務報告及財務業務文件之主要內容有虛偽或隱匿之情事，有關人員對於發行人所發行有價證券之善意取得人、出賣人或持有人因而所受之損害，應負賠償責任。前揭規定並未針對持有人有限縮解釋，且考其立法意旨，證券交易法增訂持有人之規定係為使投資人之保護更行周延，故特於 2006 年 1 月 11 日公布修正之證券交易法將持有人納入保障範圍。基於上開原則凡於 2006 年 1 月 13 日（證券交易法修正生效日）之後公布不實財務報告之行為人，對行為時之持有人（不論係 2006 年 1 月 13 日前買進或 2006 年 1 月 13 日買進）因已具有預見可能性，應負損害賠償責任，尚無法律不溯及既往之問題」(金管會 2007 年 8 月 1 日金管證六字第 09600315074 號函)。依上開函釋，公司如於證交法第 20 條之 1 生效（2006 年 1 月 13 日）之後公告不實之財務

報告，對於公告之時持有該公司有價證券之人，應負賠償責任。有價證券持有人雖係於不實財報公告之前買進，亦可請求賠償。基此，丙可依證交法第 20 條之 1 善意持有人之規定，請求損害賠償。惟學者對於是否賦予證券持有人賠償請求權，有不同見解。

(二) A、甲係證交法第 20 條之 1 之賠償義務人

論述同上述乙之部分。

(三) 交易因果關係、損失因果關係與抗辯事由

司法判決有認為持有人不能依詐欺市場理論推定交易因果關係，其理由略以：「按不實財報公告前已取得有價證券之持有人，就其因而所受之損害，依證交法第二十條之一第一項至第三項規定，為損害賠償請求者，須證明其損害及與不實財報間有因果關係。原審認第二類授權人不能依「詐欺市場理論」推定其買入股票與財報不實間有交易因果關係，投保中心復未能舉證證明第二類授權人係誤信系爭財報，仍持有宏○公司股票致受有跌價損失，難認其損失與系爭財報不實間有因果關係。爰就第二類授權人部分為投保中心敗訴之判決，於法並無違誤」(最高法院 104 年度台上字第 225 號民事判決)。基此，丙若能舉證交易因果關係與損失因果關係，仍能請求損害賠償。對於丙之舉證，賠償義務人得舉反證以反駁請求權人之主張。

【閱卷委員的話】

首先，本題的測驗重點在於證券交易法第 20 條第 2 項及第 20 條之 1、持有人之定義與因果關係、抗辯事由與整體案件綜合判斷。大部分考生均有對證券交易法第 20 條第 2 項與第 20 條之 1 進行討論，但有部分考生可能因為題目閱讀沒有仔細，而將本題以證券交易法第 32 條加以論述。其次，持有人之定義與範圍，以及本題乙、丙是否得以持有人身分主張權利，應適切討論與說明，若單以本題事實敘述直接認定是否為持有人之論述，恐顯速斷，應附理由加以論述。最後，A 公司與甲會計師應負擔何種責任與抗辯時，應仔細引用前述條文以及系爭疑義，輔以立法意旨、實務案例、學術討論等理由加以闡述與說明，避免責任定性與論述內容歧異，或流於題目抄寫後逕以結論。